

1510314-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510314-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510314-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 01 de maio de 2022, por volta das 15h31min, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e Decreto Federal nº 06/2020 (decretos de calamidade pública), na Travessa André Lendel, nº 07, Vila Matilde, nesta cidade e Comarca, tinha consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 83 (oitenta e três) microtubos de plástico, do tipo eppendorf, pesando 17,6g (dezessete gramas e seis decigramas), contendo cocaína, em pedras do tipo crack; 54 (cinquenta e quatro) invólucros de plástico, pesando 44,5g (quarenta e quatro gramas e cinco decigramas), contendo cocaína; 34 (trinta e quatro) invólucros de plástico, pesando 51,5g (cinquenta e um gramas e cinco decigramas), contendo maconha; 02 (dois) comprimidos, pesando 0,8 (oito decigramas) contendo metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecido como ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente, a fls. 14/15.

Laudo de Constatação, a fls. 17/20.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 101/104.

Comprovante de depósito judicial da quantia apreendida a fls. 53 (R\$ 194,25).

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, Laudo de Constatação de fls. 17/20 e Laudo Pericial de fls. 101/104, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada a sua participação ativa na venda dos entorpecentes.

Interrogado na fase policial, o acionado confessou a traficância, alegando "que as drogas eram suas e que estava traficando no local e que, assim que visualizou a presença de viaturas da PM, jogou a droga em cima do telhado da casa vizinha e tentou sair do local, sendo abordado pelos Policiais Militares em seguida; ao ser questionado sobre o dinheiro (R\$194,25), afirmou ser produto da venda de drogas no local." (fls. 07).

Nesta audiência judicial, manteve a admissão dos fatos.

Corroborando as próprias palavras do réu, temos o restante da prova acusatória, de todo séria, encimada nos relatos dos policiais militares Fernando de Souza e Bruno Ricardo Corrêa da Cunha, responsáveis pela prisão do acusado.

Narraram, então, em depoimentos absolutamente harmônicos, que estavam em patrulhamento pela área dos fatos, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizaram alguns indivíduos em uma casa abandonada. No local, estavam três indivíduos, posteriormente identificados como Marcio Francisco Areal, FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA e Lucas Henrique Lima Martins Silva, sendo certo que Lucas e FERNANDO estavam saindo apressadamente da tal casa abandonada assim que as viaturas chegaram ao local, enquanto Marcio estava parado em frente ao imóvel. Em buscas

pelo local, visualizaram no telhado da residência vizinha uma sacola, conseguindo recuperá-la, sendo que, em seu interior, havia diversos papérols e eppendorfs com substâncias que aparentavam ser droga (cocaína, maconha, crack e ecstasy), além da quantia de R\$ 194,25 (cento e noventa e quatro reais e vinte cinco centavos) em dinheiro trocado. Diante disto, resolveram por questionar tais indivíduos. Em entrevista, FERNANDO disse que a sacola encontrada era sua e admitiu que estava traficando no local, tendo jogado a sacola em cima do telhado da casa vizinha ao notar a aproximação das viaturas. Já Marcio disse que a casa onde a droga estava jogada no telhado era sua, porém, desconhecia a origem da droga. Por sua vez, Lucas confirmou ser usuário de drogas e, em revista pessoal, foi encontrado um pino de cocaína com ele. Neste cenário, foram todos conduzidos à presença da autoridade policial.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado tinha consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 83 (oitenta e três) eppendorfs, pesando 17,6g (dezessete gramas e seis decigramas), de crack; 54 (cinquenta e quatro) invólucros de plástico, pesando 44,5g (quarenta e quatro gramas e cinco decigramas), contendo cocaína; 34 (trinta e quatro) invólucros de plástico, pesando 51,5g (cinquenta e um gramas e cinco decigramas), contendo maconha; e 02 (dois) comprimidos, pesando 0,8 (oito decigramas) contendo metilenodioximetanfetamina (MDMA), conhecido como ecstasy, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, subdivididas em porções individuais, mormente porque, além de confessar a autoria delitiva, não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas exclusivamente para seu uso pessoal, sequer comprovando emprego lícito. Doutro lado, consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado, especialmente porque os relatos das testemunhas foram objeto de admissão pelo réu, em audiência judicial.

A grande quantidade de drogas apreendidas, num total de 173 (cento e setenta e três) porções, os tipos de entorpecentes encontrados, dentre os quais destaco o crack e a cocaína, altamente lesivos, o modo de acondicionamento, subdivididas as drogas em porções individuais, as circunstâncias do flagrante, nas quais localizado inclusive um cliente do comércio espúrio, que confirmou em solo policial ter adquirido a droga do ora acusado, a apreensão de considerável quantia de dinheiro em espécie, num total de R\$ 194,25 (cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), os depoimentos firmes dos policiais que o abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o acusado praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória. Com efeito, em que pese irrelevante a não identificação precisa do cliente, no caso em tela tal foi possível, corroborando com o acervo probatório, já contundente, que milita em desfavor do acionado, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico nas modalidades de trazer consigo e guardar as drogas, comprovando a destinação mercantil.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmada a responsabilidade do acionado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis.

Todavia, não me passa despercebida a grande quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, dentre elas entorpecentes de natureza altamente lesiva, como a cocaína e o crack.

Destarte, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo suas penas base em patamar 1/6 superior ao mínimo, alcançando a pena de cinco anos e dez meses de

reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias multa.

Em segunda fase, presente a circunstância atenuante decorrente da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d)", do Código Penal, e, doutro lado, inexistentes circunstâncias agravantes, reduzo as penas do acusado para que tornem ao mínimo legal, sempre observada a súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça

Revedo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminosa, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento de penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que, em que pese as circunstâncias absolutamente suspeitas do flagrante, não existem provas de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

De tal forma, considerando as circunstâncias do caso concreto, tanto objetivas como subjetivas, entendo por bem reduzir suas reprimendas em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

Malgrado em situação parelha, diante do meu entendimento pessoal, o regime fechado seja o mais adequado, acredito que diante das circunstâncias de fato apuradas no processo tal rigor não merece aplicação, me parecendo suficiente e adequado o regime aberto.

Adira-se, neste ponto, ainda, a determinação contida no julgamento do HC nº 596.603, do STJ, rel. Ministro MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, in verbis:

Dispositivo. À vista de todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para: 1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena. 2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto. 3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão – salvo os casos do item anterior – determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente. 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento

da pena.

Ainda, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada à acionada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Sobre o tema: Apelação Criminal 1510746-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 1501914-98.2019.8.26.0603; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 0000345-68.2018.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo previsto em lei, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada à acionada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Diante da pena final aplicada, defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, caso deseje apelar.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em benefício de FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do sentenciado lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido nos autos a fls. 53 (R\$ 194,25) ao FUNAD, posto se tratar de evidente produto do comércio espúrio de entorpecentes. Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06